

1501323-37.2021.8.26.0581

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... praticado mediante violência e o outro, o tráfico de mais de uma substância entorpecente. Além disso, o sentenciado tem outro processo por tráfico em andamento, já tendo sido condenado em primeira instância (fls. 44/45). Assim, tenho que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Recomende-se o réu na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel-SP - cep 18650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501323-37.2021.8.26.0581 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501323-37.2021.8.26.0581

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2307341/2021 - DEL.POL.AREIÓPOLIS, 21330214 - DEL.SEC.BOTUCATU, 1237/21/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2307341 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2307341 - DEL.POL.AREIÓPOLIS, 1237/21/200 - DEL.POL.AREIÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

WILLIAN MOURA BENEDITO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 03/06) em face WILLIAN MOURA BENEDITO, já qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado como incurso nos arts. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 329, caput, do Código Penal (CP) e 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (LD) Consta da denúncia que, no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 19h00min, na Rua Vereador Inácio Leite, n.º 800, Núcleo Habitacional Comendador José Zill, na cidade de Areiópolis, nesta comarca, o réu supostamente dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano. Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o réu, mediante violência, resistiu à abordagem dos policiais militares João Paulo Rosman e Clésio Leão dos Santos, no exercício de

suas funções. Consta, também, que nas mesmas condições fático-temporais, o acusado trazia consigo e mantinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 20 (vinte) pinos de cocaína, com peso líquido de 3,88 gramas e 01 (uma) pedra grande de crack, com peso líquido de 88,15 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 03 (três) munições intactas, 01 (uma) balança de precisão, 09 (nove) microtubos de plástico vazios, 01 (um) rolo de embalagem plástica, 01 (um) aparelho celular e R\$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais) em espécie.

Narra a exordial acusatória que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando, ao passarem por uma rua da cidade, avistaram um indivíduo que trafegava com uma motocicleta, a qual estava com a placa levantada, o que lhes chamou atenção. Ato contínuo, aproximaram-se do indivíduo, que, em alta velocidade, empreendeu fuga ao notar a aproximação policial. Então, diante do comportamento do acusado, ele foi perseguido pelos agentes, perdeu o controle da motocicleta e foi ao chão. Ao conduzir sua motocicleta, sem habilitação e em alta velocidade, o que resultou em sua queda, gerou perigo de dano. Após a queda, ainda assim, o réu, a pé, persistiu em sua fuga, mas foi alcançado e abordado. Durante a abordagem Willian resistiu, tentou fugir novamente, por isso foi necessário o uso de força física para contê-lo. Realizada busca pessoal, no interior do bolso da bermuda que o acusado vestia foram encontrados 20 (vinte) pinos de cocaína, bem como a quantia de R\$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais). Indagado pelos policiais sobre a existência de mais entorpecentes, o acusado informou que tinha em depósito, em sua residência, mais entorpecentes, onde foram realizadas buscas, tendo sido encontradas as demais drogas apreendidas.

Auto de prisão em flagrante delito à fl. 07.

Em audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em preventiva (fls. 51/54).

A decisão de fls. 75/78 acolheu a manifestação do Ministério Público e determinou o arquivamento do feito em relação ao delito do art. 12, caput, da Lei n.º

10.826/2003. Ademais, determinou a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia.

Notificado (fls. 97/101), o réu apresentou defesa prévia (fls. 104/105).

Recebida a denúncia (fl. 112), foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a d. representante do Ministério Público requer a condenação, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, postula a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em consideração à natureza e à quantidade de drogas, bem como aos maus antecedentes do acusado; pleiteia, ainda, o afastamento da privilegiadora e a fixação do regime inicial fechado (fls. 209/220).

A d. defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição do réu, por ausência de provas suficientes à condenação; subsidiariamente, requer o perdão da pena de multa ou sua aplicação no mínimo legal (fls. 224/235).

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e ausente, ainda, qualquer nulidade processual, passo ao exame do mérito.

1. Do crime do art. 309 do CTB

Apesar de se extrair do acervo probatório coligido, de forma clara, que o réu dirigia sem habilitação, não foi produzida qualquer prova acerca do perigo de dano concreto a terceiros que teria sido gerado pela condução do veículo, elemento exigido pelo tipo penal.

A testemunha JOÃO PAULO ROSMAN, policial militar, narrou que, na data dos fatos, verificaram uma moto Honda preta circulando com placa levantada; que, diante dessa característica, acompanharam a motocicleta; que deram sinal de parada, mas foram desobedecidos; que o acusado se desequilibrou e caiu do veículo; que, após a tentativa de fuga e a resistência, conseguiram conter o acusado. Relatou que,

posteriormente, constataram que o acusado não era habilitado para conduzir motocicleta.

A testemunha CLÉSIO LEÃO DOS SANTOS, também policial militar, aduziu que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento, quando viram de longe uma motocicleta com placa levantada; que tentaram abordar o condutor, mas foi desobedecida a ordem de parada; que, uns metros depois, ele caiu; que o parceiro do depoente desembarcou e foi tentar contê-lo.

Deve-se consignar que o crime capitulado no art. 309 do CTB é de perigo concreto, isto é, as elementares típicas (condições de existência do crime) exigem a condução de veículo sem a devida permissão ou habilitação e a ocorrência de situação de perigo concreto de dano.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 309 DO CTB (DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO). CRIME DE PERIGO CONCRETO. SÚMULA 83/STJ. PERIGO REAL OU CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de risco real ou concreto de dano. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal de origem, com base no material cognitivo produzido nos autos, concluído não haver provas do perigo concreto de dano causado pela condução inabilitada do agente, a pretensão de condenação, na medida em que demanda a incursão no conjunto fático-probatório, não se coaduna com a via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1668855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) (grifei).

Na mesma linha, entende o E. TJSP:

Apelação. Direção de veículo sem habilitação. Pleito defensivo de absolvição.

Necessidade. Crime de perigo concreto. Ausência de prova do perigo gerado a terceiros na hipótese específica dos autos. Precedentes do STJ. Inteligência do enunciado da Súmula 720 do STF. Absolvição que se impõe. Apelo provido. (TJSP; Apelação Criminal 0001476-35.2017.8.26.0210; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaíra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2019; Data de Registro: 17/02/2019)

Apelação. Condução de veículo sem habilitação. Absolvição por ausência de comprovação de perigo concreto. Possibilidade. Delito previsto pelo artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a demonstração de perigo de dano. Ausência de laudo pericial ou situação fática que demonstre que o ato praticado pelo réu causou perigo de dano. Absolvição que se mostra cabível. Apelo provido. (TJSP; Apelação Criminal 0021834-63.2012.8.26.0576; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2016; Data de Registro: 10/03/2016)

O mesmo aspecto também é mencionado na Súmula 720 do STF, que dispõe:

Súmula 720: O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres (grifei).

Ainda que o acusado tenha caído do veículo, para a configuração do tipo penal é necessária a geração de risco a terceiros, e não somente ao próprio agente, uma vez que o risco unicamente à própria pessoa é irrelevante ao Direito Penal, conforme o princípio da alteridade.

Essa conclusão é aferida do inteiro teor do julgado acima colacionado, verbis:

“Ora, no caso em tela, a acusação não logrou êxito em produzir nos autos qualquer elemento de prova hábil a apontar eventual perigo causado ao patrimônio ou integridade física alheia. O simples fato de ter fugido dos policiais em alta velocidade e, na sequência, sofrido acidente automobilístico sozinho, sem o envolvimento de terceiros, ao cair da motocicleta em uma lombada, não faz presumir a existência de perigo de dano a terceiros.

Não houve, ademais, a comprovação como era de rigor, considerando o ônus de prova da acusação de que havia transeuntes ou outros veículos automotores na via pública no momento dos fatos, afastando, pois, o perigo concreto da conduta praticada pelo agente no caso em exame, restando tão somente aplicável a sanção inerente à seara

administrativa." (TJSP; Apelação Criminal 0001476-35.2017.8.26.0210; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guaíra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2019; Data de Registro: 17/02/2019, pp. 5-6).

No caso em tela, o conjunto probatório dos autos é insuficiente a demonstrar, com a segurança necessária, que o acusado desenvolveu conduta que ensejou situação de perigo concreto a terceiros, pois inviável a presunção desse risco.

Por essa razão, o réu deve ser absolvido da imputação da prática do crime do art. 309 do CTB, por ausência de prova suficiente à condenação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

2. Do crime do art. 329, caput, do CP

Quanto ao delito de resistência, a materialidade dos fatos está comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 07); termos de depoimento (fls. 08/10); boletim de ocorrência n.º 1237/2021 (fls. 12/15); termo de interrogatório (fls. 22/23); relatório final do inquérito policial (fls. 67/68); boletim de ocorrência PM n.º 202111100412860 (fls. 183/190); bem como prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria está demonstrada, uma vez que a prova oral colhida em juízo corrobora os elementos informativos amealhados na fase pré-processual.

A testemunha JOÃO PAULO ROSMAN, policial militar, apontou que, quando o acusado caiu da motocicleta, o depoente desembarcou da viatura e tentou abordar o réu, mas esse conseguiu se desvencilhar e fugiu; que o seu parceiro contornou a via e abordou o acusado; que quando viu os dois estavam em luta corporal; que conseguiu chegar perto e ajudar seu parceiro; que tiveram que conter o acusado e algemá-lo; que seu colega teve escoriações no braço por conta da resistência do réu.

No mesmo sentido, a testemunha CLÉSIO LEÃO DOS SANTOS, também policial militar, aduziu que, após a queda do acusado da motocicleta, o parceiro do depoente desembarcou e foi tentar contê-lo, mas não conseguiu; que o depoente, então, com a viatura, fez o cerco e alcançou o réu, mas esse resistiu à prisão; que foi necessário uso de força física para contê-lo e algemá-lo.

O réu, em seu interrogatório, declarou que estava indo ao banco para sacar dinheiro; que é apenas habilitado de carro e estava na moto, essa que comprou com muito esforço; que por isso fugiu, já que não queria perder a moto; que os policiais jogaram a viatura em cima dele para que ele parasse; que ficou com o ombro para fora do lugar; que nessa hora foi abordado; que desceram da viatura e lhe deram dois chutes na cabeça; que correu para um estabelecimento de xerox. Ocorre que a versão do réu está isolada da prova testemunhal colhida e, por isso, não merece guarida. Os policiais militares ouvidos em juízo descreveram de modo unânime que, durante a abordagem, o réu resistiu e tentou fugir tanto no veículo quanto a pé, tendo investido com violência contra o policial Clésio, o que obrigou os agentes de segurança a utilizar força física moderada para conter o acusado. Assim, denota-se com clareza a prática do crime de resistência, consistente na conduta do réu de se opor, mediante violência, à execução de ato legal dos policiais.

3. Do crime do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006

No que concerne ao delito de tráfico de drogas, observo que a materialidade dos fatos está comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 07); termos de depoimento (fls. 08/10); boletim de ocorrência n.º 1237/2021 (fls. 12/15); auto de exibição/apreensão (fls. 16/17); termo de interrogatório (fls. 22/23); laudo pericial provisório (fls. 37/41); relatório final do inquérito policial (fls. 67/68); laudo pericial definitivo (fls. 91/93); boletim de ocorrência PM n.º 202111100412860 (fls. 183/190); bem como prova oral colhida. Sobreleva notar que a substância apreendida (cocaína, na forma de sal e de crack) se encontra expressamente prevista na Portaria n.º 344/98 e Resolução n.º 104 da Anvisa, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

No que concerne à autoria do acusado, tenho que essa também foi cabalmente demonstrada.

Sobre essa imputação, a testemunha JOÃO PAULO ROSMAN declarou que, feita busca

peçoal no acusado, encontraram setecentos e poucos reais em dinheiro e alguns pinos de cocaína; que cientificaram a rádio quando ele começou a resistir; que chegou apoio e pelotão de Força Tática; que, quando disseram ao acusado que iriam pedir um mandado de busca, ele começou a gritar e ficou desesperado. Narrou que o acusado então resolveu assumir os fatos, disse que tinha um pouco de droga em casa, uma arma de fogo e que sua família não sabia; que, diante desse contexto, se deslocaram até a casa dele, e o pai do réu autorizou a entrada, que isso ficou gravado; que as buscas foram acompanhadas pelo pai dele, e que o acusado ficou na viatura porque estava muito alterado. Explicou que, na busca domiciliar, encontraram, na cômoda, dentro de uma caixa de sapatos, uma pedra bruta de crack, porções de crack embaladas prontas para venda, uma balança de precisão e três munições; que foram para a UPA, porque ele estava machucado da queda da moto e da luta corporal, e, posteriormente, à DP; que tinham informações de que ele praticava o tráfico de drogas; que as denúncias eram anônimas, de populares, e ocorriam desde a época em que ele saiu da cadeia; que nunca conseguiram abordá-lo. Informou que um dos pontos dele é a Cohab, e que o acusado também vendia drogas em festas.

Para mais, a testemunha CLÉSIO LEÃO DOS SANTOS, policial militar, corroborou que, em busca peçoal, encontraram 20 pinos de cocaína e 700 reais com o acusado; que conheciam o acusado e sabiam que ele incitava a população contra a equipe, por isso ligaram e pediram reforços; que, quando chegaram na base, perguntaram sobre a origem do dinheiro, e o acusado disse que tinha acabado de fazer o "recolhe"; que disseram a ele que pediriam mandado de busca, porque tinham informações de que ele que era traficante; que o acusado disse que iria falar, porque seu pai não sabia dos fatos, mas o réu tinha droga na casa. Informou a testemunha que os policiais fizeram contato com o Seu Rogério Cristiano, pai do acusado, que lhes autorizou a entrada e acompanhou a revista; que isso tudo foi filmado; que encontraram, em uma caixa de sapatos na cômoda, 3 munições de calibre 38, 3 porções de crack e mais uma porção bruta; que levaram o acusado para a UPA e depois para a DP. Mencionou que tinham denúncias anônimas, e que o acusado já foi preso uma vez pelo tráfico de drogas.

A testemunha ANA CAROLINE LACERDA SOARES disse que era vizinha do acusado e amiga da esposa dele; que, nesse dia, a Daniela (esposa do acusado) tinha ido à sua casa; que a polícia invadiu a sua casa na data dos fatos sem autorização; que perguntaram sobre a Daniela; que reviraram a cama e o guarda-roupas; que perguntaram se havia drogas na casa, mas não havia; que apreenderam a sua balança de pesar bolos, pois vendia bolos de pote; que morava na Rua Otávio Máximo dos Santos n.º 20; que não conhecia os policiais que entraram na sua casa; que sua balança era pequena e marrom; que o Willian era trabalhador e que estava trabalhando, mas que não sabia onde ele trabalhava, apenas via ele chegando do serviço.

A informante DANIELA DA SILVA SOUZA, esposa do acusado, declarou que, no dia do ocorrido, estava fazendo uma maquiagem e que, antes de ir embora, ligou para Willian comprar algumas coisas; que combinaram de se encontrar na porta do mercado, mas que depois disso Willian não atendeu mais; que desceu à casa da sua vizinha para que ela ligasse para ele, mas ela não tinha créditos; que então foi à casa da sua avó, quando recebeu uma ligação dizendo que o acusado tinha sido preso; que, nessa data, invadiram a casa da sua avó, da sua amiga e da sua irmã; que moram aos fundos da casa do pai de Willian; que depois de 15 dias da prisão de Willian, foram à casa da depoente atrás dela; que estavam com fotos suas perguntando dela para os outros, mas que não sabe o motivo dessa procura.

A testemunha LUCAS MATEUS MARINELLI narrou que morava na esquina da Rua Vereador Inácio Leite, a aproximadamente 100 metros de onde aconteceu a abordagem; que estava com sua namorada tomando cerveja na rua, quando viram Willian no chão, e a viatura parada; que Willian estava com uma motocicleta preta; que acreditava que Willian tivesse comprado há pouco tempo essa motocicleta; que ele tinha CNH, mas não se sabe se na categoria de moto; que colocaram o acusado na viatura e desceram; que, depois de uns 15, 20 min, chegaram algumas viaturas da força tática; que trabalhava com o acusado na irrigação; que já haviam terminado o expediente no momento da abordagem.

A testemunha JOEL PAES DE OLIVEIRA informou que não viu o que aconteceu. Só soube

informar que o acusado chegou correndo e invadiu seu estabelecimento; que o policial chegou e levou o acusado; que seu estabelecimento tinha câmeras de segurança, mas que elas estavam com problemas e, por isso, não foi possível fazer a gravação.

Interrogado, o acusado negou a prática dos fatos. Aduziu que, em seus bolsos, só havia o dinheiro e o cartão; que foi algemado e levado para a base da Polícia Militar de Areiópolis, onde foi torturado; que a Força Tática invadiu a casa da sua mulher e da sua vizinha; que essa droga não era sua; que ficou sabendo dela depois. Indagado se tinha alguma inimizade com os policiais, informou que o processo passado foi deflagrado porque o acusado se envolvera em uma briga com um parente de um policial e fingiu que estava armado; que, por isso, houve o primeiro mandado em sua casa; que o policial Clésio estava junto quando da invasão na sua casa, em 19/12/2019.

Em que pese a argumentação do acusado, com o intuito de desqualificar a atuação policial, não foram produzidos elementos que indicassem que o encontro das drogas teria sido forjado.

Não foi narrada nenhuma rixa especificamente envolvendo o réu e as testemunhas policiais que foram ouvidas na instrução, essas que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que as testemunhas de defesa não presenciaram os fatos, portanto suas declarações não foram minimamente capazes de botar em xeque a confiabilidade da ação policial realizada.

Os ofícios requisitados em audiência de instrução dão respaldo à diligência realizada, assim como o vídeo depositado em cartório (fls. 108/204 e 208). Assim, entendo que não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso (STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021; TJSP, Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019).

Dessa forma, tenho que a conduta praticada pelo acusado amolda-se ao delito de tráfico de drogas, uma vez que praticou o núcleo "trazer consigo" e, em se caracterizando a figura do art. 33 da LD como tipo misto alternativo, a prática de qualquer de seus verbos é apta a configurá-lo.

A maneira como estava acondicionada a droga - fracionada e pronta para comercialização -, a apreensão de petrechos e de grande quantia em espécie, assim como as anotações constantes da certidão de distribuições criminais do acusado, são elementos que indicam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, e sim à mercancia (art. 28, § 2º, da LD).

Ausentes majorantes e minorantes.

Não concorre a minorante do art. 33, §4º, da LD, uma vez que, apesar de o réu ser primário e possuir bons antecedentes, há elementos que indicam que ele se dedicava a atividades criminosas, uma vez que responde a outro processo pelo delito de tráfico de drogas, já tendo sido, inclusive, condenado em primeiro grau (fls. 44/45).

Nesse sentido, tenho que é possível a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, consoante jurisprudência pacificada da Terceira Seção do C. STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao

mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 (...) (EResp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017)

Ausentes agravantes e atenuantes.

Considerando que, mediante duas condutas, o acusado praticou dois delitos autônomos e com momentos consumativos diversos, incide entre as figuras o concurso material (art. 69 do CP).

Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado efetivamente praticou os delitos de resistência e de tráfico de drogas, razão pela qual deve responder criminalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria e adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006), identifico que a culpabilidade é intrínseca aos tipos penais. O réu é tecnicamente primário (fls. 44/45). Não há elementos concretos acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências dos crimes são comuns às espécies. As vítimas do crime de resistência não contribuíram para a prática delitiva. A quantidade de droga não destoia do esperado. A natureza dos entorpecentes será valorada negativamente, aumentando-se a pena em 1/6, pois o crack é droga de efeitos especialmente deletérios e alto poder viciante. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, para o delito de tráfico de entorpecentes, e em 2 meses de detenção, para o crime de resistência.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, fica mantida a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, não concorrendo majorantes e minorantes, converto as penas provisórias em definitivas.

Presente o concurso material de crimes, deixo de somar as reprimendas, por serem de naturezas diversas (art. 69 do CP).

Fica WILLIAN MOURA BENEDITO definitivamente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, a 2 meses de detenção e a 583 dias-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, c, da Lei das Execuções Penais e a jurisprudência do E. TJSP.

O regime inicial será o semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, b, do CP.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP e art. 43 da Lei n.º 11.343/2006).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de seu quantum, e, ainda, em virtude da violência inerente ao delito do art. 329 do CP, circunstâncias que impedem a substituição (art. 44, I, do CP).

Incabível o sursis penal, também em razão do montante da reprimenda (art. 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para:

a) ABSOLVER WILLIAN MOURA BENEDITO, já qualificado, da imputação da prática do delito previsto no art. 309 do CTB, com fulcro no art. 386, VII, do CPP;

b) CONDENAR WILLIAN MOURA BENEDITO, já qualificado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 329 do CP e 33, caput, da LD, na forma do art. 69 do CP, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e de 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e de 583 dias-multa, sendo cada dia-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Mantenho a prisão preventiva (art. 387, § 1º, do CPP), porquanto inalteradas as condições que a justificaram, bem como presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Necessário o recolhimento do acusado ao cárcere para resguardar a ordem pública, uma vez que está sendo condenado por dois delitos, sendo um praticado mediante violência e o outro, o tráfico de mais de uma substância entorpecente. Além disso, o sentenciado tem outro processo por tráfico em andamento, já tendo sido condenado em primeira instância (fls. 44/45). Assim, tenho que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Oficie-se à SAP para que transfira o réu para estabelecimento prisional compatível com o regime ora fixado. Expeça-se guia de execução provisória.

Custas pelo réu, ressalvada hipótese de gratuidade processual (art. 804 do CPP).

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Como a quantia apreendida está intrinsecamente vinculada à prática delitiva – produtos da mercancia da droga –, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD (art. 91, II, do CP).

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeça-se guia de execução definitiva;
- e) oportunamente, arquivem-se.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se.

Intimem-se.

São Manuel, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA